

1500802-89.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... como a desclassificação do crime de tráfico para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06 (fls. 368/371).

A defesa, por sua vez, pediu a absolvição do acusado. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06. Quanto ao crime de roubo, requereu a condenação do acusado por roubo simples, afastando-se a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

1ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500802-89.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500802-89.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2145395/2022 - DEL.POL.PLANTÃO PENAPOLIS, 25243305 - DEL.POL.PLANTÃO PENAPOLIS, 726/22/310 - DEL.POL.PLANTÃO PENAPOLIS, 2145395 - DEL.POL.PLANTÃO PENAPOLIS, 2145395 - DEL.POL.SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 726/22/310 - DEL.POL.SANTOPOLIS DO AGUAPEI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AIRES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

S E N T E N Ç A

Processo nº. 1500802-89.2022.8.26.0603 (Controle nº 1500/2022).

Vistos.

AIRES DA SILVA, qualificado nos autos, foi preso em flagrante, denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, e no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 27 de maio de 2022, por volta das 21:50 horas, na Rodovia Assis Chateaubriand, na cidade de Santópolis do Aguapeí, comarca de Birigui/SP, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (faca), um aparelho celular, marca Redmi Xiaomi, pertencente à vítima Marcelo Garcia de Almeida.

Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias acima descritas, AIRES DA SILVA, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 81,83 gramas de cocaína, conforme laudo de constatação de fls. 13/16 e laudo químico toxicológico-definitivo de fls. 152/154.

Recebida a denúncia em 08 de julho de 2022 (fls. 135/136), o acusado foi regularmente citado (fl. 162), apresentando defesa escrita às fls. 190/192.

Durante a instrução, foram tomadas as declarações da vítima e colhidos os depoimentos de 01 (uma) testemunha arrolada em comum, sobrevivendo, ao final, o interrogatório do acusado (fls. 230/231).

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a parcial procedência da ação, com a condenação do réu pelo crime de roubo, bem como a desclassificação do crime de tráfico para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06 (fls. 368/371).

A defesa, por sua vez, pediu a absolvição do acusado. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06. Quanto ao crime de roubo, requereu a condenação do acusado por roubo simples, afastando-se a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca. Pediu ainda, a fixação da pena no mínimo legal; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; a fixação do regime aberto; e o direito de o réu recorrer em liberdade (fls. 259/264).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar os delitos de roubo consumado, com a incidência de uma causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma e tráfico de drogas (artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal e artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal).

A ação penal é totalmente procedente, respeitado o entendimento exposto pela acusação e defesa em suas alegações finais.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia restaram suficientemente comprovadas.

Nesse sentido, temos: o auto de prisão em flagrante (fl. 01); a nota de culpa (fl. 06); o boletim de ocorrência (fls. 07/09); o auto de apreensão e exibição (fls. 10/11); o auto de entrega de fl. 17; o auto de avaliação de fl. 114; os laudos periciais de fls. 152/154 e 237/241; o relatório final (fls. 103/105); as declarações da vítima do roubo; os depoimentos das testemunhas e as indigestas e contraditórias negativas apresentadas pelo acusado em ambas as fases da persecução penal.

Na delegacia, o acusado disse que viu um caminhão estacionado no posto, adentrou o caminhão, subtraiu um aparelho de telefone celular e saiu sem ver o motorista. Tentou ligar o celular, mas como precisava de senha retornou até o caminhão para tentar devolver o celular, porém, ao abrir a porta, o motorista, de longe gritou "vai embora", neste momento o acusado saiu correndo com o celular. Disse que estava com dívidas de drogas e iria entregar o celular como pagamento. Estava voltando para casa, quando avistou os policiais, correu e jogou o celular, mas foi abordado. Confessou que subtraiu o aparelho e disse que não possui nenhuma arma e que a faca apreendida pertence aos policiais. Quanto a droga, disse que encontrou dentro da viatura, guardou na cueca e, na Delegacia, foi revistado e encontraram a droga.

Disse ser usuário de drogas (fl. 05).

Em juízo, passou a dizer que foi agredido pelos policiais militares, motivo pelo qual confessou a prática do roubo com emprego de faca e o tráfico, dizendo que a droga lhe pertencia (fls. 230/231).

Como se vê, o acusado apresentou contradições. Na delegacia, confessou apenas a subtração do celular, negando o roubo com emprego de arma branca e a prática do tráfico; todavia, em juízo, alterou a versão e passou a dizer que confessou a prática do roubo com emprego de faca e o tráfico (afirmando que a droga encontrada lhe pertencia), pois foi agredido pelos policiais militares.

A confissão livre e espontânea, no tocante à subtração em si, prestada no processo serve como importante elemento de convicção para evidenciar a autoria e amparar a condenação, quando encontrar sustentação nos demais elementos de convicção produzidos, como é o caso.

De fato, no caso, a confissão parcial do réu quanto à subtração encontrou total respaldo nas demais provas carreadas aos autos, todavia, diante das contradições relacionadas a pontos de fundamental relevância para o deslinde da causa, como acima mencionadas, não há como se dar credibilidade às versões apresentadas pelo acusado. Logo, a negativa quanto ao emprego de arma branca e ao tráfico de drogas bem como a alegação de estado de necessidade, restaram contraditórias e isoladas, se cotejadas às demais provas coligidas sob o crivo do contraditório, que apresentaram grau de idoneidade bem mais elevado, como se verá doravante, tratando-se de mero expediente utilizado na tentativa de afastar a responsabilização penal por condutas efetivamente praticadas.

Com efeito, a vítima, ouvida em ambas as fases da persecução penal, disse que parou no posto de combustível para jantar; ao retornar em seu caminhão, acionou a partida e foi até o caminhão que estava estacionado atrás, ao retornar no caminhão, deparou com o acusado, que lhe apontou uma faca e disse "perdeu, perdeu" e saiu do caminhão correndo com seu celular. Foi atrás do acusado para ver a direção que estava indo, quando avistou policiais rodoviários e informou o ocorrido, salientando que o acusado tinha tatuagem no rosto. Pouco depois, os policiais apresentaram o acusado, o celular e a faca, o que reconheceu de pronto. Em juízo, reconheceu novamente o acusado como sendo o autor do roubo. Ficou sabendo também que foi encontrada droga com o acusado (fls. 04 e 230/231).

Como se viu, a vítima reconheceu o acusado na audiência de instrução, sob o crivo do contraditório. Afora isso, na delegacia, reconheceu o acusado e a faca usada no roubo.

Não se pode olvidar que, nos delitos de furto e roubo, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de excepcional importância, sobretudo quando harmoniosa e coincidente com o conjunto probatório, como é o caso.

As declarações das vítimas foram confirmadas pelos demais elementos de prova colhidos na instrução.

A testemunha Edman Silazaki de Oliveira, policial militar, ouvido em ambas as fases da persecução penal, relatou que estava no Restaurante do posto de combustível, quando foi informado por um caminhoneiro de que havia acabado de ser vítima de roubo. A vítima informou que estava com o caminhão estacionado no pátio do posto e que um indivíduo com tatuagem no rosto, armado de uma faca, lhe abordou e disse "perdeu" e fugiu em seguida levando seu celular. Iniciou patrulhamento, identificou o acusado pela tatuagem no rosto, o qual passou a correr, jogou uma faca e um telefone celular. Foi abordado e confessou ser o autor do roubo. O acusado negou a propriedade da faca e quanto ao telefone celular, assumiu ser o produto do roubo. Posteriormente, na delegacia, em revista minuciosa, foi encontrado dentro da roupa íntima do acusado, um saco plástico contendo cocaína, que ele assumiu a propriedade, mas não disse a destinação. A vítima reconheceu o acusado como sendo o autor do roubo, o aparelho como sendo de sua propriedade e a faca apreendida como sendo a arma utilizada no crime (fls. 02 e 230/231).

No mesmo sentido, foi o depoimento do policial João Vitor Nascimento Lins, ouvido na delegacia (fl. 03).

Os policiais confirmaram o reconhecimento do acusado feito pessoalmente pela vítima, bem como o reconhecimento da faca utilizada no roubo, além da apreensão de

considerável quantidade de cocaína localizada dentro da roupa íntima do acusado. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Tal depoimento somente não terá valor quando se evidenciar o interesse do servidor na investigação penal, e quando suas declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

Importante salientar que não existe qualquer circunstância que justificasse o interesse dos policiais em prejudicar o acusado, ou em imputar falsamente a ele a prática de condutas definidas como crimes, sobretudo porque ele não apontou nada que justificasse essa circunstância.

Não prospera, portanto, a alegação do acusado de que foi agredido pelos policiais e que a faca foi "plantada" para incriminá-lo, já que tais alegações não foram amparadas por qualquer prova produzida pelo réu.

No mais, já houve análise na audiência de custódia, sendo que, naquela ocasião, determinou-se a expedição de ofício para Corregedoria da Polícia Militar para apuração dos fatos.

O juiz do processo é obrigado a analisar todas as teses defensivas apresentadas, no entanto, não está obrigado a acreditar em versões do acusado que destoam dos demais elementos de prova, como é o caso.

Confira, neste sentido, julgado cuja relatoria coube ao E. Desembargador Luís Soares de Melo:

"... Tem-se que a prova que lastreou a condenação é absolutamente forte, segura e incontroversa. Já o inconformismo do apelante, em último plano, não têm suporte algum na prova que, muito ao reverso do que se pretende fazer ver, se disse, é positivamente forte. Daí dando idéia segura de que agiu com acerto pleno o Tribunal Popular. Imaginar-se hipótese diversa, "data venia" e em face às evidências escancaradas nos autos, seria verdadeiramente fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio, em total e completo desapego às normas genéricas da verdade e de bom-senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos. Nada obstante deva estar o julgador e, com maior dose de razão, o colegiado, sempre atento e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto que representam sua irre realidade. O julgador e para além disso, o colegiado, com maior razão, então, que é e deve ser dotado de bom-senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade, como aqui" (TJ-SP, Apelação nº 0033861-83.2009.8.26.0576 , Comarca de São José do Rio Preto, 4ª Câmara de Direito Criminal).

O crime foi consumado, porque o roubo atinge a consumação no momento em que o objeto material é retirado da esfera vigilância do sujeito passivo, ingressando na livre disponibilidade do autor, ainda que a posse não seja tranquila e se dê por pouco tempo. Aliás, mesmo que tenha ocorrido a devolução do bem subtraído e não tenha a vítima sofrido desfalque em seu patrimônio, isso ocorreu em razão da ação dos policiais, que abordaram o acusado e conseguiram detê-lo, depois da inversão da posse dos bens. Evidente, pois, a caracterização do delito de roubo, na forma consumada.

Lembro, outrossim, que o artigo 157, em nenhum momento, exige, para a tipificação do delito de roubo, o efetivo desfalque no patrimônio da vítima. Em outros termos, praticada a subtração mediante violência ou grave ameaça, se a coisa for recuperada pela vítima, tal fato não afasta a responsabilidade penal do agente.

Quanto à grave ameaça, a vítima foi categórica em mencionar que o réu a ameaçou com uma faca. Logo, diante da evidente grave ameaça contra a vítima exercida com o emprego de uma arma branca, restou evidente o dolo do acusado de praticar o crime de roubo, ficando, pois, afastada a pretensão de desclassificação da conduta para o crime de roubo simples, como pretendido pela defesa.

De outra parte, quanto à causa de aumento relativo ao emprego de arma branca,

anoto que tal fato restou comprovado com a apreensão da faca (fls. 10/11) e pelas declarações da vítima, testemunhas e laudo pericial de fls. 237/241. A vítima foi categórica em afirmar que foi ameaçada com uma faca.

Quanto ao entorpecente apreendido, a perícia apontou que consiste realmente em "cocaína" (exame químico-toxicológico de fls. 152/154).

Assim, a quantidade do entorpecente apreendido, ou seja, 81,83 gramas de cocaína, a forma de acondicionamento da droga (acondicionada em uma única porção bruta); e a ausência de justificativa plausível para a apreensão da quantidade de entorpecente, estão a caracterizar a traficância.

Nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado. Lembre-se que o réu foi denunciado por trazer consigo a droga.

Anoto que o tipo penal do artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 é chamado de tipo misto alternativo, possuindo vários núcleos, dentre eles, trazer consigo, conduta essa efetivamente praticada pelo acusado.

Importante anotar, outrossim, que o simples fato de a droga não ter sido apreendida em grande quantidade, por si só, não afasta a tipificação do crime de tráfico.

Aliás, atualmente, os traficantes vêm utilizando desse modo de agir (distribuição de pequenas porções entre vários entregadores), a fim de dificultar a apreensão da droga e a caracterização do crime de tráfico.

Portanto, a prova coletada nos autos é substancial e convincente, ficando evidente a autoria por parte do réu, nos crimes ora apurados.

Não há, pois, como se deixar de reconhecer que no dia, horário e local indicados na denúncia, o acusado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, um aparelho celular, marca Redmi Xiaomi, pertencente à vítima Marcelo Garcia de Almeida.; e trazia consigo 81,83 gramas de cocaína, substância entorpecente determinante de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regular, para fins de entrega a consumo de terceiros.

As condutas do denunciado encontram tipicidade na exata correspondência com os delitos definidos no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, e artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade. Neste ponto, não há que se falar em desclassificação do crime para o do artigo 28 da Lei de Drogas, haja vista que o acusado sequer assumiu que o entorpecente apreendido lhe pertencesse.

Assim, irrelevante o fato de o réu ser ou não usuário, porque não assumiu a propriedade da droga, não havendo sequer espaço para se falar em desclassificação para o crime de porte de droga para uso próprio.

Por outro lado, ainda que se admitisse o acusado como usuário e ainda que ele tivesse assumido que a droga lhe pertencesse, esse fato, por si só, não lhe impediria de exercer a traficância. Muito pelo contrário, há grande afinidade entre uma e outra condutas: se o réu é usuário há um bom tempo, isso facilita o ingresso no submundo do crime, principalmente no mercado de substâncias tóxicas.

Diante desse quadro, a condição de ser o agente usuário de droga não exclui a possibilidade de ser condenado como traficante, porque são situações que não se excluem.

De uma forma ou de outra, portanto, não há que se falar em desclassificação do crime imputado para o de uso de drogas previsto no artigo 28 da Lei nº. 11.343/06. Ademais, não há como reconhecer eventual estado de necessidade, já que não vislumbro a presença do perigo atual, como exigido pelo artigo 24, caput, do Código Penal, além do que poderia o réu ter realizado outras condutas lícitas que não o tráfico de drogas.

Reconheço a ocorrência dos delitos e passo a aplicar as penas separadamente.

Roubo.

O réu não registra maus antecedentes e as demais circunstâncias previstas no artigo

59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis, ensejando a fixação da pena em seu mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, elevo a pena em 1/6 (um sexto) em virtude da agravante da reincidência (fls. 267/268 – processo nº 1501701-58.20208.26.0603), resultando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa. No mais, não há outras circunstâncias agravantes ou quaisquer atenuantes a serem consideradas.

Ainda nesta fase, deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea, porque, embora tenha o réu confessado a subtração, negou o a ameaça com emprego de arma branca, bem como alegou estado de necessidade, que é uma excludente de ilicitude, procurando eximir-se de sua responsabilidade penal. Anoto que o entendimento deste Juízo é no sentido de que a confissão espontânea a que alude o artigo 65 do Código Penal, como circunstância determinante de alguma redução de pena, é aquela sem ressalvas, sem desculpas para o gesto criminoso, a qual não restou configurada no caso.

Na terceira fase, acrescento 1/3 (um terço) em razão da causa de aumento decorrente do emprego de arma branca. Isso porque, com a introdução de outras causas de aumento no roubo, totalizando seis, quando presente apenas uma delas, deve-se impor o aumento mínimo (1/3); duas, o aumento de três oitavos (3/8); três, cinco doze avos (5/12); quatro, onze vinte e quatro avos (11/24); cinco, seis ou mais, o máximo (1/2).

Com o aumento do parágrafo anterior, a pena atinge 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, a qual torno definitiva.

Tráfico de Drogas.

O acusado não ostenta mau antecedente e as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal não lhes são desfavoráveis, autorizando a fixação da pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, elevo a pena em 1/6 (um sexto) em virtude da agravante da reincidência (fls. 267/268 – processo nº 1501701-58.20208.26.0603), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. No mais, não há outras circunstâncias agravantes ou quaisquer atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não vislumbro a existência de causas de aumento ou diminuição de pena. Não há como se aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, porque o réu é reincidente, o que afasta de vez a aplicação desse benefício.

Torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Reconheço o concurso material entre os delitos, de modo que as penas serão somadas, conforme dispõe o artigo 69 do Código Penal, resultando em 12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 597 (quinhentos e noventa e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, a qual torno definitiva.

Diante da gravidade das condutas, mesmo levando-se em conta a detração penal disposta na Lei nº 12.736/12 (art. 2º, que acrescentou o § 2º ao art. 387 do CPP), as penas privativas de liberdade do réu devem ser cumpridas no regime inicial fechado, obrigatoriamente, pois o crime de tráfico é equiparado a hediondo, conforme estatuído no art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90.

Além disso, o roubo é crime grave, que revela temibilidade do agente e que vem gerando o clima de violência e de intranquilidade que aflige a sociedade brasileira atual, estando a exigir medidas eficazes para combatê-lo.

Em outros termos, justifica-se a imposição de regime fechado para o início de cumprimento da pena com fundamento na periculosidade do agente decorrente da prática de roubo, máxime em vista da crescente onda de assalto e de crimes violentos que assolam o país.

Este regime é, portanto, o único compatível com este tipo de infração e com a frieza e desfaçatez de seu autor.

O acusado deverá continuar a responder preso a este processo, pois assim permaneceu durante a instrução e ainda estão presentes os requisitos da custódia cautelar, como se verá adiante.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR AIRES DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão (resultado da soma das penas de 06 anos, 02 meses e 20 dias referente ao crime de roubo, e 05 anos e 10 meses relacionado ao crime de tráfico de drogas), em regime inicial fechado, e pagamento de 597 (quinhentos e noventa e sete) dias-multa, no seu valor mínimo unitário legal (art. 49 e parágrafos do CP), dando-o como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, e artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Consigno que o acusado ficou preso cautelarmente desde 28/05/2022 até a presente data, período sobre o qual fica reconhecida a detração penal, para fins de cumprimento do restante da pena, nos termos do que dispõe o artigo 1º da Lei nº 12.736/12.

Deve, no entanto, a Serventia, ao expedir a Carta de Guia, atentar para se consignar a condenação total constante do dispositivo acima, com as observações consignadas no parágrafo anterior (detração penal).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender incabível tal providência.

Não obstante o julgamento do Habeas Corpus n. 50394-60, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se entendeu por inconstitucional a vedação à substituição por penas restritivas de direitos para o crime de tráfico, por afronta ao princípio da individualização da pena, até então não se trata de decisão proferida com efeito erga omnes.

Foi editada a Resolução nº 5/2012, do Senado Federal, que, nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, suspendeu a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, que vedava de forma abstrata (sem análise do caso concreto) a conversão em penas restritivas de direito, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo em decisão no Habeas Corpus já mencionado acima.

Com a mencionada Resolução, não se pode mais afirmar que o efeito do julgamento daquele habeas corpus não é para todos. Entretanto, a intenção do Supremo Tribunal Federal, ao decidir desta forma, e o Senado Federal, ao editar a resolução, foi somente deixar à prudente análise do magistrado do caso concreto se o réu tem ou não direito a ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, e não que essa substituição seja admitida em qualquer caso de tráfico de drogas, indistintamente. Pensar assim seria um contrassenso.

Confira, neste sentido, decisão proferida em Apelação Criminal que analisou sentença proferida por este juízo:

"... Inviável, nesse passo, a pretendida substituição carcerária por restritivas de direito, porque, embora o teor da recente Resolução nº. 5/2012 do Senado Federal, fundada na decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do Habeas Corpus, nº. 97.256/RS - mencionado nas razões recursais -, em controle difuso de constitucionalidade, in casu, permanece impossível, data vênua, a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, ou mesmo a concessão de sursis, pois o crime de tráfico de entorpecentes revela a gravidade peculiar que desestabiliza a vida em sociedade e fere de morte a saúde pública, pois enquanto fomenta, simultânea e irremediavelmente - até as pedras estão cansadas de saber -, a violência, a destruição de lares e das famílias e a prática de n crimes, sobretudo para o fim de viabilizá-lo, tanto assim que, por força de norma constitucional, é assemelhado aos delitos hediondos, cuja pena deve ser cumprida no regime prisional inicial fechado, determinação esta que se mostra incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou com a suspensão condicional da pena, de modo que não se consegue compreender ou avaliar, por mais que se esforce, qual

seria a pena substitutiva ou as condições do sursis adequadas ao traficante, emergindo sintomático que – até o momento – jurista sério algum tenha ousado sugerir-las..." (TJ-SP, Apelação Criminal nº 0009435-15.2010.8.26.0077, 5ª Câmara Criminal, rel. Des. Juvenal Duarte, j. 19.04.2012).

Ainda no mesmo sentido, confira julgamento proferido em processo que tramitou por essa comarca de Birigui:

"Também não faz jus a apelante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados a tráfico de drogas é incompatível com a gravidade e as circunstâncias em que o crime é cometido, não havendo qualquer tipo de violação ao princípio da individualização da pena.

Este entendimento deve prevalecer, notadamente ao se considerar a vedação expressa trazida pelo artigo 44 da Lei de Drogas.

Com efeito, o benefício consistente na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tem por objetivo primordial o de possibilitar a ressocialização de indivíduos de baixa periculosidade, que praticaram delitos de pequeno grau de lesividade social.

Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de pequeno, médio ou grande porte, não tem o perfil de iniciar o cumprimento de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor, as quais virão a repercutir a toda a coletividade. Ressalta-se que uma das exigências previstas no artigo 44, inciso III, do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é a de que os motivos e as circunstâncias indiquem como suficiente tal medida, para a repressão do agente da conduta delituosa.

Conforme já fundamentado, tal benefício não se coaduna com as graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causa, não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental, mas também ao corpo social (deseestrutura familiar, estímulo à prática de outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).

Muito embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do "Habeas Corpus" nº 97256/RS, tenha expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no § 4º, do artigo 33, da Lei 11343/06, é de se ressaltar que tal decisão não possui o erga omnis.

E mesmo a resolução nº 5 do Senado Federal, de 15 de fevereiro de 2012, que suspendeu a eficácia da referida expressão, não acarreta direito subjetivo do agente que praticou o grave delito do tráfico de entorpecentes a tal conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Frise-se, ainda, que o artigo 44 da Lei de Drogas mantém tal vedação ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput. Considerando que o § 4º é tão somente uma causa de diminuição do delito previsto no caput – e não um crime autônomo –, é possível concluir que a vedação a ele também se aplica.

Neste aspecto, ensina Guilherme de Souza Nucci que "(...) o fato de haver sido prevista uma causa de diminuição de pena para o traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações criminosas, não afasta a tipificação da sua conduta como incursas no artigo 33, caput e § 1º, que são consideradas similares a infrações penais hediondas, como se pode observar pelas proibições enumeradas no artigo 44 da Lei 11343/06. Salienta-se, ademais, o cuidado legislativo em vedar a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, típica opção de política criminal para o tráfico ilícito de drogas. Não se pode criar uma nova infração penal, a partir da mera aplicação de causa de diminuição de pena. Por isso, o tráfico ilícito de drogas será sempre considerado equiparado a hediondo, ainda que comporte, por opção legislativa, pena mais branda, quando os requisitos do § 4º estiverem presentes" (in "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas", 5ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p.372).

Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau" (Apelação Criminal nº 0002364-20.2014.8.26.0077. Rel. Toloza Neto).

Não bastassem esses argumentos, anoto ainda que o acusado é reincidente e a pena fixada ultrapassa quatro anos, o que também afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, incs. I e II, CP).

O acusado deverá continuar a responder preso por este processo, pois sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 68/70), ocasião em que foram expostos os fundamentos necessários para a custódia cautelar, os quais ficam aqui reiterados, como razão de decidir.

Ademais, continuam presentes os requisitos que recomendam a custódia cautelar do acusado, mormente porque praticou delito equiparado aos hediondos. Nesse aspecto, a ordem pública merece resguardo.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, com fundamento nos artigos 59 da Lei nº 11.343/06, c.c. o § 4º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, acrescentado pela Lei nº 11.464/07.

Por fim, em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, após 85 (oitenta e cinco) dias contados da publicação da sentença, tornem os autos conclusos para revisão da necessidade de manutenção ou não da decisão que manteve a prisão preventiva, mantendo-se os autos na fila "acompanhamento de prisão preventiva".

A incineração da droga já foi determinada (fls. 68/70) e realizada (fl. 216), nada havendo a ser decidido a respeito.

Diante da natureza do objeto apreendido a fls. 10/11 (faca), determino, desde já, sua destruição, expedindo-se o necessário e comunicando-se a Sala de Armas e Objetos Apreendidos.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Com o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 28 da Resolução nº 23.399/13 do TSE, instruindo o ofício com cópias da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Custas, na forma da lei.

P. R. I.

Birigui, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA